



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro Robson Marinho

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **6/11/2024**

Exame Prévio de Edital – **Referendo e Julgamento**

M-001: TC-019512.989.24-5; TC-0020145.989.24-0 e TC-020329.989.24-8

Representada: Prefeitura de Diadema

Responsável: José Antonio da Silva - Secretário de Saúde

Representantes: Giuliano Balsini Merolli, Nicolas José Rossi da Silva e Licit Prestação de Serviços Sorocaba Ltda.

Assunto: Representação contra o Edital da Concorrência nº 2/2024, Processo Administrativo nº 12.547/24, certame promovido pela Prefeitura de Diadema, objetivando a contratação integrada de empresa para a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo e a execução de obras de construção do novo hospital municipal, incluindo a reforma e ampliação de edificação existente.

Valor Estimado: n/c

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Edson Rodrigues Veloso (OABSP 144778) e Camila de Andrade Alves Lima (OABSP 310660)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. TÉCNICA E PREÇO. CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL EXCLUSIVA POR MEIO DA CAO. ADMITIR APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS. JUSTIFICATIVA PARA A ELEIÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA. RESTRITIVIDADE NA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA. PARTICIPAÇÃO CONSORCIADA. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DA REDAÇÃO PERTINENTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AVCB. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECOMENDAÇÕES.

Relatório

Representações intentadas por Giuliano Balsini Merolli, Nicolas José Rossi da Silva e Licit Prestação de Serviços Sorocaba Ltda. contra o Edital da Concorrência nº 2/2024, do tipo técnica e preço, Processo Administrativo nº 12.547/24, certame promovido pela Prefeitura de Diadema para a contratação integrada de empresa para a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo e a execução de obras de construção do novo hospital municipal, incluindo a reforma e ampliação de edificação existente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

O edital, assinado por José Antonio da Silva - Secretário de Saúde, é datado 5/7/2024, as representações foram protocoladas em 17/9, 25/9 e 3/10/24 e a sessão pública estava agendada para o dia 8/10/24.

O representante Giuliano questiona:

a) para aspectos relacionados à engenharia, o edital não permite a comprovação da capacidade técnica operacional por meio da apresentação de atestados, mas apenas por meio de Certidão de Acervo Operacional – CAO. Acrescenta que o edital não considera a apresentação de atestados forma hábil à tal comprovação, servindo apenas para complementação ao CAO.

O representante Nicolas questiona:

b) condições para a comprovação da qualificação financeira (balanço patrimonial e índices contábeis) sem justificativas.

c) não fixação de parcelas de maior relevância, bem como seus quantitativos, para demonstração da capacidade técnica operacional.

Foi afastada de plano indagação acerca de subcontratação de MEs e EPPs por configurar consulta, uma vez que o rito do exame prévio de edital é impróprio para o pleiteado.

A representante Licití questiona:

d) inexistência de justificativa técnica para fixação de número máximo de consorciados.

e) data-base para reajuste de preços relativa ao mês da apresentação das propostas e não à data do orçamento.

f) vinculação indevida de pagamento a contar da emissão da nota fiscal correspondente e não da medição do serviço.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

g) inconsistências na minuta de contrato: g1) não previsão de prazo para resposta aos pedidos de repactuação do contrato e de reequilíbrio econômico-financeiro; g2) ausência de critérios para atualização monetária.

h) regramentos para comprovação da capacidade técnica profissional: h1) limitação de tempo para comprovação da capacidade técnica profissional. h2) é restritiva, para arquiteto urbanista, em compatibilização de projetos arquitetônico e complementares de engenharia; h3) para engenheiro mecânico, relacionada a sistemas de climatização com filtragem absoluta.

i) regramentos para comprovação da capacidade técnica operacional: i1) limitação de número de atestados para fins de somatório; i2) relacionada à multipavimentos ou múltiplos pavimentos, uma vez que a técnica empregada independe da envergadura da obra; i3) inadequada necessidade de comprovação “com obtenção de AVCB”, que é licença relacionada à execução de projetos e não de obra; i4) relacionada a sistemas de climatização com filtragem absoluta.

Em razão de aspectos que recomendavam o exame do ato cuja legalidade se pôs sob suspeita, inclusive em virtude da jurisprudência desta Corte, a fim de evitar possível prejuízo à competição e violação irreparável a direito e uma vez preenchidos os requisitos arrolados no Regimento Interno deste Tribunal, foi determinada singularmente a suspensão do certame e oficiamento à Origem para que encaminhasse a esta Corte cópia do edital impugnado, além de justificativas para as questões suscitadas, determinando aos responsáveis, inclusive, que se abstivessem da prática de quaisquer atos relacionados ao presente certame, até sua deliberação final.

Regularmente notificada, a origem reconheceu a necessidade de aprimoramento da redação do edital em relação aos itens “e” e “g.1” e defendeu a improcedência dos demais questionamentos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Instada, a ATJ se manifestou pela procedência parcial dos pontos impugnados, posicionamento acompanhado por sua Chefia e MPC.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Voto

TC-019512.989.24-5

TC-020145.989.24-0

TC-020329.989.24-8

De início, peço referendo da decisão que suspendeu o certame.

No mérito, a tecnicidade da matéria exige a devida atenção ao bom trabalho realizado pela ATJ.

São incontroversos os pontos afetos ao item “e”, uma vez que a origem se comprometeu a alterar a redação do edital para vincular a data-base para reajuste de preços relativa à data do orçamento, bem como ao item “g.1”, pois afirmou que vai definir expressamente o prazo para resposta aos pedidos de repactuação do contrato e de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos questionados.

Os aspectos relacionados aos itens “b”, “f”, “h1”, “i1” e “i2” são improcedentes.

O item “b” reclama da ausência de justificativas para os índices contábeis eleitos, bem como para a exigência para apresentação de balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais.

A origem demonstrou que as justificativas para a adoção dos índices contábeis estão presentes no processo administrativos, tendo a ATJ ratificado sua pertinência em relação ao objeto licitado e à jurisprudência desta Corte. Quanto ao balanço patrimonial, a exigência encontra guarida no artigo 69, I, da Lei 14133/21.

O reclamado no item “f” não se sustenta uma vez que a previsão do pagamento após a emissão da nota fiscal tem amparo nos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

No item “h1” é questionada a limitação de tempo para comprovação do tempo de formado de profissional membro da equipe técnica,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

em alegada contrariedade ao artigo 67, §2º, da Lei 14133/21, que veda a imposição de limitações de tempo para fins de demonstração da capacitação técnica.

Ocorre que a demonstração do tempo de formado está relacionada à nota da proposta técnica, não havendo a caracterização da aventada limitação de tempo para fins habilitatórios.

A crítica relativa ao item “i1”, afeta à limitação do somatório de atestados, não prevalece, pois, igualmente, é regramento relacionado à proposta técnica e não à habilitação.

No caso do item “i2”, em que é questionada a previsão no edital de prova de experiência em projeto e execução de instalações elétricas em múltiplos pavimentos, bem como a execução de obras multipavimentos, a ATJ se posicionou pela improcedência em razão da pertinência das *“justificativas técnicas da Municipalidade de Diadema, principalmente em razão do porte do empreendimento e de sua localização no endereço da atual sede administrativa da Prefeitura, que impõem restrições logísticas importantes para uma obra de tamanho vulto. (...) o fato de o instrumento convocatório não demandar quantitativos mínimos para a qualificação técnica em projeto e execução de instalações elétricas, nem área mínima para execução de obras, mitiga a restrição das exigências habilitatórias com a especificação “multipavimentos” ou “múltiplos pavimentos”, a ponto de afastar a restrição ilegal à ampla competitividade”*.

Os demais questionamentos, abordados nos itens “a”, “c”, “d”, “g2”, “h2”, “h3”, “i3” e “i4”, demandam ajustes no texto do edital.

No caso do item “a”, a discussão recai sobre a imposição de comprovação da capacidade técnica operacional.

A crítica tem dois pontos de relevância: o fato de a capacidade operacional somente poder ser demonstrada por meio da CAO – Certidão de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Acervo Operacional, tendo sido atribuída aos atestados apenas função complementar à CAO, não sendo hábeis para o atendimento às exigências do edital de forma isolada; essa distinção foi feita apenas para os casos de engenharia, sendo que para arquitetura e urbanismo é aceita a comprovação apenas por atestados.

A CAO é um documento introduzido pela Resolução CONFEA nº 1.137/2023 para atendimento ao art. 67, II, da Lei Federal n. 14.133/21.

Todavia, a ATJ fez ponderações no sentido de que:

“...a CAO é um documento criado recentemente, cuja emissão pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia pode ainda estar em fase de implementação, a depender da Unidade da Federação. Para o CREA-SP, consta informação que o prazo para obtenção é de até 20 (vinte) dias a partir da confirmação do pagamento da taxa(6) , mas cuja contagem pode ser reiniciada (isto é, o prazo pode ser devolvido ao CREA), se for necessária a substituição ou o envio de novos documentos pela empresa para requerimento da Certidão.

Por se tratar de instrumento novo, é plausível que uma empresa interessada na licitação não detenha a CAO e não consiga obtê-la em tempo hábil para participar da Concorrência.

Outrossim, depreende-se que a CAO ainda não é uma forma consagrada de comprovação da expertise operacional das empresas de engenharia, ao contrário dos atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, que eram expressamente mencionados no § 1º do art. 30 da revogada Lei Federal n. 8.666/93.

Embora a Prefeitura Representada tenha enfatizado o vulto do empreendimento (orçado em R\$ 329.502.538,57) para justificar a requisição da Certidão (CAO) emitida pelo CREA, o fato é que os atestados fornecidos pelas pessoas jurídicas de direito público ou privado são suficientes para comprovar que a licitante executou serviços com características semelhantes às parcelas de maior relevância. Mesmo porque, o vulto do empreendimento, por si só, não justifica, tecnicamente, o formato do documento que deve ser exigido.

Nesse contexto, parecem-me demasiadamente restritivas a comprovação da aptidão técnica operacional unicamente por meio da CAO e o estabelecimento de uma diferenciação entre documentos a serem apresentados por arquitetos e engenheiros, que não parece razoável.”

Além disso, não parece razoável haver distinção na forma como engenheiros devem comprovar a capacidade técnica operacional se comparado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

com o regramento afeto aos arquitetos e urbanistas, até porque tanto o CREA quanto o CAU estão sujeitos às modificações introduzidas pela nova lei de licitações.

Ainda sobre esse aspecto, a ATJ faz uma série de recomendações para aprimoramento da redação do edital. Como se trata de pontos para os quais a origem não foi especificamente notificada a se manifestar, as sugestões podem ser remetidas ao campo das recomendações.

No item “c” o representante questiona a não fixação das parcelas de maior relevância, bem como seus quantitativos, para a comprovação da capacidade técnica operacional.

Por um lado, a leitura do edital revela que o item 7.9.4 traz a relação das parcelas de maior relevância para o fim reclamado. Por outro, de fato, não foram estabelecidos quantitativos.

A origem esclarece que o edital visou apenas a comprovação qualitativa da expertise da interessada e não quantitativa. Na medida que a afirmação feita nos autos vincula a ação da comissão no certame, no sentido de que nenhuma interessada será afastada em razão de quantitativos, o trazido pela origem pode ser recepcionado neste caso.

Todavia, de plano, a Assessoria Técnica destacou que não foram encontradas justificativas para os itens relacionados como parcela de maior relevância, o que demanda atenção da origem para o suprimento dessa lacuna.

Especificamente quanto aos itens lá dispostos, peço vênica para destacar trechos da manifestação da Assessoria Técnica.

No caso da crítica ao sistema de climatização (itens “h3” e “i4”), a ATJ considerou restritiva a especificidade de condensação à água, pois a solução para o sistema de climatização poderá prever alternativas de expansão indireta com água ou outro fluído. Ainda sobre esse tópico, a assessoria técnica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

observou que o atestado de execução do serviço de projeto de climatização deverá comprovar que a experiência prévia ocorreu em “edificação hospitalar”, o que afronta a Súmula 30 desta Corte.

Segue trecho de interesse:

“Não se olvida que sistemas de climatização semelhantes possam ser executados em shopping centers, edifícios corporativos, faculdades/centros universitários, ou mesmo em outros Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), como UBSs, UPAs e CAPS, de forma que não se sustenta a necessidade de expertise anterior em projetos desse sistema unicamente em unidades hospitalares.

Em síntese, compreendo que a Administração deva permitir atestados que contemplem sistemas de climatização do tipo expansão indireta através de condensação à água ou outro fluido, bem como exclua a necessidade de que tenham sido realizados em “edificação hospitalar”.

Apesar de não mencionada na representação, essa mesma limitação à esfera hospitalar é percebida na parcela de maior relevância relativa à “execução de obras de edificação hospitalar ou estabelecimento assistencial de saúde (EAS), de múltiplos pavimentos, com leitos, contemplando UTI, centro cirúrgico e CME (...)”, também qualificada pela Assessoria Técnica como potencialmente desestimulante à participação de interessados.

A ATJ destacou que a parcela “elaboração de projetos de arquitetura para edificação hospitalar ou estabelecimento assistencial de saúde, modelado em BIM” também é restritiva. Esse ponto também não foi aventado nas representações.

Segue trecho de interesse:

“A exigência de comprovação de experiência prévia na modelagem BIM requer que haja previsão de seu uso na contratação, bem como justificativas para tanto. Não localizei tais condições no ETP e no Termo de Referência.

A utilização do BIM (Building Information Modeling) ainda é incipiente no país e, de certa forma, soa-me uma restrição desarrazoada no caso concreto, por não haver previsão clara da obrigatoriedade de sua utilização nos projetos e na execução contratual como um todo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Além disso, a exigência direciona o BIM somente à arquitetura, o que não garante a interoperabilidade com outros projetos diretamente ligados a essa disciplina, como os de instalações elétricas, hidráulicas e de gases medicinais, essenciais para o funcionamento de uma unidade hospitalar. Também não identifiquei a previsão de apresentação de todos os projetos em padrão de dados abertos (IFC), o que é fundamental para que o BIM possa ser operacionalizado.

Compreendo que, para a especificação do BIM na fase habilitatória, o ato convocatório e seus anexos deveriam contemplar as disposições elencadas no Manual de Obras e Serviços de Engenharia editado por esta E. Corte de Contas (...)"

Esses pontos, em razão de não ter sido dada a oportunidade de apresentação de justificativas a respeito, são aspectos a serem destinados ao campo das recomendações.

O item “d” aborda a limitação a duas empresas para a participação consorciada e os esclarecimentos da origem tem por base apenas facilitar a gestão do contrato.

Alguns aspectos evidenciam a falta de fundamento mais robusto para tal restrição. O primeiro deles é o vulto do ajuste, estimado em R\$ 329.502.538,57. O segundo aspecto é que se trata de contratação integrada, que inclui o projeto básico e a execução pela contratada, sendo fases do objeto que normalmente são atendidas por empresas distintas.

Além disso, a ATJ considerou relevante o fato de haver a possibilidade de que a vencedora do certame opte por construir a edificação hospitalar em estrutura de concreto armado pré-moldado ou em estrutura metálica, cujo projeto estrutural, a fabricação dos perfis metálicos, a montagem dos componentes e a execução das estruturas metálicas são atividades realizadas por poucas empresas altamente especializadas, bem como que o edital não previu a possibilidade dada pelo artigo 67, §9º, da nova lei de licitações: “O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado”.

Todos esses pontos revelam a fragilidade da justificativa apresentada pela origem para a restrição à participação consorciada imposta no edital.

Quanto ao item “**g.2**”, a instrução dos autos evidenciou que, de fato, não foi estabelecido critério de atualização monetária em caso de atraso de pagamento, uma vez que o item 18.6.6 do edital e a cláusula 7.7 da minuta do contrato tratam somente dos juros de mora a serem acrescidos.

O item “**h2**” é procedente, nos termos explicados pela ATJ, porque *“a exigência de expertise do profissional formado em arquitetura e urbanismo em “compatibilização de projetos” é excessiva, pois não é privativa dessa área de atuação: é plenamente plausível que o(a) arquiteto(a) não seja a responsável pela compatibilização dos projetos na execução contratual, e sim o(a) engenheiro(a) civil”*.

No caso do item “**i3**”, que trata do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), a Assessoria Técnica esclareceu que muito embora seja necessária sua obtenção para a Unidade Hospitalar, para fins de habilitação técnica somente é possível a imposição de atestados em projetos ou execução de serviços relacionados a “Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio”, o que demanda a retificação do edital.

Diante do exposto, encurto razões e voto pela **procedência parcial** dos pontos questionados, devendo a origem corrigir o ato convocatório nos seguintes termos:

1) admitir a comprovação da capacidade técnica operacional também por meio de atestados, inclusive nos casos de engenharia.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

2) explicitar as justificativas técnicas para a eleição das parcelas de maior relevância.

3) permitir a comprovação da capacidade técnica referente ao sistema de climatização em relação a outros fluídos e não somente à água.

4) deixar de exigir comprovação da capacidade técnica relativa a atividades específicas, nos termos da Súmula 30 desta Corte.

5) aprimorar os regramentos afetos à participação consorciada, nos termos destacados pela Assessoria Técnica.

6) estabelecer critério de atualização monetária em caso de atraso de pagamento.

7) deixar de restringir a comprovação de expertise em relação à compatibilização de projetos apenas por profissional formado em arquitetura e urbanismo, estendendo essa possibilidade também ao engenheiro civil.

8) retificar a redação do edital no que diz respeito ao AVCB.

9) atender ao recomendado pela Assessoria Técnica para fins de aprimoramento do texto do edital.

A Administração deverá ainda publicar o novo texto do edital e reabrir o prazo legal para oferecimento das propostas, nos moldes do § 1º do art. 55 da Lei 14.133/2021.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os processos.